



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05/02/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-023084.989.24-3.

Representante: Rom Card – Administradora de Cartões Eireli.

Representada: Prefeitura Municipal de Cedral.

Responsáveis: Paulo Ricardo Beolchi de Lucas – Prefeito à época da subscrição do edital; e
Irineo Beolchi Junior – Prefeito.

Advogada: Miriam Athie (OAB/SP n.º 79.338).

Assunto: Representação formulada contra o processamento do Pregão Eletrônico n.º 32/2024, Processo Administrativo n.º 2562/2024, Processo Licitatório n.º 48/2024, que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou tecnologia similar, para servidores do Município de Cedral.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representação formulada pela empresa **Rom Card – Administradora de Cartões Eireli** contra o processamento do Pregão Eletrônico n.º 32/2024, Processo Administrativo n.º 2562/2024, Processo Licitatório n.º 48/2024, da Prefeitura de Cedral, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



tecnologia similar, para servidores municipais.

De acordo com informação disponibilizada no instrumento apresentado, a sessão de disputa de preços estava agendada para as 09h00 de 20/09/2024. Afora isso, consta “Termo de Adjudicação” do objeto em disputa do sítio eletrônico da Representada.

Em suma, a impugnante vislumbra irregularidades na condução do certame, do qual afirma ter participado.

Nessa linha, descreve que, por ocasião do início da competição na data estipulada, houve empate entre as propostas com taxa de administração igual a 0%, tendo a Comissão de Licitação, à vista disso, passado à verificação do atendimento aos critérios de desempate preconizados no subitem 8.1 do ato convocatório.

Dessa forma, explica, quanto ao primeiro e segundo parâmetros de desempate fixados, consistentes, respectivamente, no desenvolvimento pelas licitantes “*de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho*” e “*de programa de integridade*”, nessa ordem, que continuou empatada com a empresa Mega Vale Administradora de Cartões Ltda., tendo as demais participantes sido desclassificadas.

Conservada a igualdade, afirma que a última diretriz de resolução da igualdade entre as propostas, estabelecida com base na regionalidade, foi equivocadamente aplicada, resultando na declaração de sua concorrente como vencedora do torneio com base em sua distância com relação ao Município.

Sobre isso, pormenoriza que o item 8.1 – subitem 3.1 não estabelece em sua redação como requisito de desempate a distância da competidora da sede do órgão promotor da disputa, mas sim que a licitante esteja localizada, neste caso concreto, no Estado de São Paulo, em consonância com o artigo 60, § 1º, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021.

Portanto, considera que “*Como ambas as licitantes empatadas ao final do certame estão estabelecidas no Estado de São Paulo, a correta orientação para o deslinde do certame seria considerar o requisito da regionalidade igualmente cumprido, seguindo-se aos demais critérios de*



desempate, e persistindo a equivalência realizando-se sorteio ao final”.

Dando seguimento, compreende que a ordem de desempate a ser observada pelo Poder Público deve se iniciar pela “*preferência de contratação às ME/EPP*”, prevista no “*caput*” do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, devendo ser excluídas da disputa as demais participantes; ultrapassada essa fase, deverão ser examinados os requisitos preconizados no artigo 60 da Lei n.º 14.133/2021 apenas entre as competidoras remanescentes, ocasião da qual não poderão participar as não enquadradas como micro e pequenas empresas; e, persistindo a igualdade, deverá ocorrer sorteio apenas entre as licitantes dotadas dos referidos portes, nos termos do artigo 45, inciso III, da mencionada legislação complementar.

Em benefício de sua tese, colaciona precedentes judiciais.

Agrega que “não se olvide considerar que a preferência de contratação inscrita no art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 seria aplicável somente na hipótese de empate ficto, posto que por decorrência lógica se estende também ao empate real [...]”.

Resume que “presta-se a presente denúncia para anular-se o resultado do certame, para que verificado o empate, seja inicialmente respeitada a preferência de contratação às ME/EPP, e na sequência verificado o atendimento de todos os critérios de desempate do art. 60 da Lei n.º 14.133/21, apenas entre as empresas enquadradas nesses portes, excluindo-se da disputa as demais, e sendo por fim realizado sorteio entre as remanescentes, persistindo a equivalência”.

Assim, requer:

- a) o recebimento e admissão da presente denúncia;
- b) o deferimento de medida cautelar para a suspensão do Pregão Eletrônico n.º 032/2024, promovido pelo Município de Cedral/SP, ou de eventual contrato que deste possa ter advindo, até a resolução integral do mérito da causa;
- c) ao final, seja julgada inteiramente procedente a denúncia para:
 - I. a anulação de todo o processo licitatório em comento, após a desclassificação das demais licitantes que não atenderam ao critério de desempate de desenvolvimento de programa de equidade de gêneros;
 - II. que seja considerado preenchido o requisito de desempate da regionalidade pela Denunciante, para que seja retomada a sessão e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



verificado o atendimento pelas licitantes classificadas dos demais critérios de desempate do art. 60 da Lei n.º 14.133/21, seguindo-se a ordem do dispositivo, respeitando-se assim o princípio da legalidade, sendo por fim realizado sorteio entre as duas licitantes classificadas, persistindo o empate.

Ante o vislumbre de potenciais riscos à higidez da licitação, em vulneração às normas de regência da matéria, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável prazo para apresentação de justificativas e cópia do processo licitatório.

No interesse da lisura da competição, determinou-se, ainda, a suspensão do procedimento licitatório.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão de 27/11/2024.

Em atendimento, a Municipalidade oferta documentos e elucidações.

De início, após citar princípios incidentes, assegura que os atos questionados não se revestem de falhas que autorizem a paralisação de todo o procedimento.

Defende, na sequência, a ocorrência de preclusão e decadência do direito de recorrer, na medida em que a representante não demonstrou interesse na prática de tal ato, tampouco apresentou razões recursais, em conformidade com a disciplina editalícia e artigo 165 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Consigna que não pode ser concretizada a análise de eventual impugnação fora do prazo, de sorte que deve ser autorizada a continuidade da instrução processual, consoante disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Deste modo, aduz que a presente representação não deve ser conhecida, porquanto não houve manifestação da reclamante no momento oportuno, tampouco acionamento das duas primeiras linhas de defesa, antes da provocação da terceira, citando, em favor de sua compreensão, o disposto no artigo 169 da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, assim como precedentes.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Dando seguimento, destaca que o certame contou com a participação de 13 (treze) proponentes, de maneira que não há se falar em ausência de competitividade.

Explica que, durante o procedimento, ocorreu empate entre algumas empresas, razão pela qual foram adotados os critérios de distinção previstos na legislação e no edital, restando, ao final, duas competidoras.

Registra que, após a aplicação do terceiro critério de desempate, sagrou-se vencedora a empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Ainda a esse respeito, refuta a possibilidade de realização de sorteio, tendo em vista que a adoção dos benefícios previstos para microempresas e empresas de pequeno porte não se aplica no presente caso, no qual não teve etapa de lances.

Frisa a observância dos parâmetros de desempate do instrumento convocatório, de maneira que os atos praticados devem ser mantidos.

Vale anotar que, em anexo à peça de defesa, traz cópia da petição inicial e de indeferimento de pedido liminar em mandado de segurança impetrado pela empresa Verocheque Refeições Ltda. (Processo n.º 1049624-82.2024.8.26.0576).

Em conclusão, requer seja a representação julgada improcedente.

Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral
opinam pela procedência da representação.

É o relatório.



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05/02/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-023084.989.24-3.

Representante: Rom Card – Administradora de Cartões Eireli.

Representada: Prefeitura Municipal de Cedral.

Responsáveis: Paulo Ricardo Beolchi de Lucas – Prefeito à época da subscrição do edital; e
Irineo Beolchi Junior – Prefeito.

Advogada: Miriam Athie (OAB/SP n.º 79.338).

Assunto: Representação formulada contra o processamento do Pregão Eletrônico n.º 32/2024, Processo Administrativo n.º 2562/2024, Processo Licitatório n.º 48/2024, que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou tecnologia similar, para servidores do Município de Cedral.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU MAGNÉTICOS COM CHIP OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO. EMPATE REAL. NECESSIDADE DE PREFERÊNCIA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. APLICAÇÃO INCORRETA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021. PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO.



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de reclamação contra atos praticados no decorrer de procedimento licitatório voltado a selecionar empresa para o fornecimento de vale alimentação, a qual se revela procedente.

Em caráter preambular, insta afastar a alegação de preclusão ou impossibilidade de conhecimento da representação em razão da falta de prévia provocação administrativa, por meio de impugnação ou recurso, na medida em que nossa atual jurisprudência não deduz, do sistema de vigilância das contratações consignado no artigo 169 da Nova Lei de Licitações¹, a instituição como requisito inafastável, para o processamento de representações nesta Corte, do prévio acionamento das instâncias de atuação e controle do órgão promotor do torneio.

Nesse sentido, a denotar a insubsistência das teses defensivas alinhavadas a esse respeito, importa trazer trecho de interesse do julgamento do TC-022651.989.23-8, em Sessão Plenária de 07/02/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli:

A princípio, insta registrar que, ao menos por ora, ausente motivo para concluir que a previsão contida no art. 169 da Nova Lei de Licitações indica ordem de prejudicialidade para acionamento, por qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, da primeira e da segunda linhas de defesa das contratações públicas antes do encaminhamento de representações ao Tribunal de Contas (terceira linha de defesa).

Com efeito, ao que parece, o dispositivo apenas segmenta, em consonância com as exigências de segregação de funções e gestão por competências (arts. 5º e 7º, Lei nº 14.133/2021), atribuições estampadas no art. 70 da CF/88, estabelecendo verdadeiro sistema articulado, contínuo e permanente de controle das contratações públicas, com desempenho paralelo e

¹ Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



concomitante, de acordo com a esfera de atuação, de servidores, empregados públicos, agentes de licitação, autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade, unidades de assessoramento jurídico, controle interno do órgão licitante e Tribunal de Contas, com a finalidade de estabelecer gestão de riscos e fiscalização preventiva e posterior, para saneamento de irregularidades e apuração de infrações administrativas.

Ainda em senda introdutória, a impetração de mandado de segurança no âmbito do Judiciário, por outra das licitantes que acorreram ao certame, ainda pendente de julgamento, não interfere na presente apreciação, porquanto as Cortes de Contas possuem, dentro de suas especiais atribuições e perfil legais e constitucionais, competência para o exame das matérias a elas submetidas.

Passando ao mérito, no que concerne ao desenrolar propriamente dito da competição, é manifesta a falta de aderência às orientações deste Tribunal, que preconizam a necessidade de, em certames que objetivam o fornecimento de benefícios alimentícios, em casos de ocorrência de empate real, ser dada preferência para contratação de eventual participante enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte e, caso existente mais de uma interessada nessa qualidade, ser realizado sorteio apenas entre tais candidatas. Somente na hipótese de a igualdade atrelar exclusivamente empresas não beneficiadas pela Lei Complementar Federal n.º 123/2006, incidem as disposições do artigo 60 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

A ilustrar a compreensão jurisprudencial prevalente nesta Corte, o julgamento do processo n.º TC-013545.989.24-6, sob relatoria do e. Conselheiro Substituto – Auditor Márcio Martins de Camargo, cujo trecho de interesse importa transcrever:

Se, de um lado, com o advento da Lei nº 14.442/22, houve a proibição da oferta de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos em certames da espécie (art. 3º, I), de outro a perspectiva factual de empate entre as licitantes diante desta vedação não autoriza, per se, a inovação de critérios de resolução da demanda não previstos taxativamente no art. 60 da Lei nº 14.133/21, na ordem ali transcrita.

[...]

Por simetria, necessário pontuar que, antes mesmo da aplicação das regras de desempate aplicáveis ao segmento em geral, deverá ser assegurado o direito de preferência às



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



microempresas e sociedades de pequeno porte, à luz do que preceitua os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06.

Em outras palavras, decretado o empate, seja ficto ou real, necessário observar esta cronologia:

a) se entre uma proponente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e outra licitante não incluída neste regime, caberá a ME ou EPP a preferência na contratação;

b) se houver mais de uma ME ou EPP, a disputa será resolvida por sorteio somente entre elas; e

c) se entre licitantes não beneficiárias da Lei nº 123/06, a solução será a aplicação do art. 60 da Lei nº 14.133/21 - com a cautela da observância estrita aos parâmetros ali estabelecidos e com a ressalva de que, neste caso, não houve previsão de sorteio na norma citada. – nota de rodapé suprimida.

De fato, no decorrer do certame ora em apreço, a corporificar a primeira impropriedade na condução da disputa, diversas concorrentes enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte ficaram em situação de igualdade, mas foram alijadas da disputa em razão da aplicação imediata dos critérios do artigo 60 da Nova Lei de Licitações e Contratos – no lugar da realização de sorteio apenas entre elas, o qual seria o único parâmetro necessário, no caso, para seleção da vencedora.

Como essa irregularidade constitui reflexo de falha na redação do edital, necessário se faz que a Prefeitura proceda à anulação de todos os atos praticados no andamento do procedimento, a fim de proceder à divulgação de ato convocatório devidamente redigido.

Se não fosse por isso, na concreta aplicação dos parâmetros do referido dispositivo da Lei Federal n.º 14.133/2021², por ocasião da intelecção

² Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; ([Vide Decreto nº 11.430, de 2023](#)) [Vigência](#)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;



da preferência por “empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;” (inciso I do § 1º), a Administração realizou distinção sem nenhuma base normativa e despida de razoabilidade.

Com efeito, ambas as empresas que restaram no páreo, ainda que após a incorreta não realização de sorteio entre todas as MEs e EPPs, situam-se no território do Estado de São Paulo, de maneira que não havia amparo para desempatar-las com fundamento no emprego desse critério.

É dizer, em se tratando de duas licitantes localizadas em território paulista, a regra em comento não abre espaço para escolher uma em detrimento da outra por causa da maior proximidade de uma delas em relação ao órgão licitante.

Por sinal, a falta de proporcionalidade da interpretação conferida pela Prefeitura fica ainda mais evidente no particular caso em apreço, tendo em vista que as empresas desempatadas por essa baliza se localizam no mesmo Município (Barueri), situado há mais de 415 km de Cedral.

A contendora reputada como vencedora assim o foi unicamente por se situar cerca de 500 metros menos distante do órgão promotor do certame (415,9km x 416,4 km), intelecção que é, à evidência, despropositada.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **procedente** a representação, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Cedral proceda à anulação dos atos praticados no processamento do Pregão Eletrônico n.º 32/2024**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 3º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, devendo, ainda, realizar a retificação

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

§ 2º As regras previstas no **caput** deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no [art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



do correspondente edital, de modo a garantir a preferência destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, sem prejuízo de, na condução do torneio, empregar corretamente os critérios do artigo 60 do mesmo diploma.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.